



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.795.341 - RS (2018/0251111-5)

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
RECORRENTE : DALVANI ALBARELLO
RECORRENTE : LUIS FABIANO LEAES NERY
RECORRENTE : SERGIO ARINO DE SOUZA
ADVOGADOS : ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338
JAIRO LUIS CUTINSKI E OUTRO(S) - RS076915
RECORRENTE : JEFERSON WBATUBA MOTA
ADVOGADO : JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. ART. 305 DO CPM. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. FALTA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS CONVERSAS. EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A EXISTÊNCIA DE ÁUDIOS DESCONTINUADOS, SEM ORDENAÇÃO, SEQUENCIAL LÓGICA E COM OMISSÃO DE TRECHOS DA DEGRAVAÇÃO. FILTRAGEM ESTABELECIDADA SEM A PRESENÇA DO DEFENSOR. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSOS PROVIDOS. DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. *A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).*

2. *É dever o Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados.*

3. *A apresentação de parcela do produto extraído dos áudios, cuja filtragem foi estabelecida sem a presença do defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizado apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa.*

4. *Reconhecida a nulidade, inegável a superveniência da prescrição, com fundamento no art. 61 do CPP.*

5. *Recursos especiais providos para declarar a nulidade da interceptação telefônica e das provas dela decorrentes, reconhecendo, por consequência, a superveniência da*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

prescrição da pretensão punitiva do Estado, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento aos recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Dr(a). JADER DA SILVEIRA MARQUES, pela parte RECORRENTE:
JEFERSON WBATUBA MOTA

Brasília (DF), 07 de maio de 2019 (Data do Julgamento)

MINISTRO NEFI CORDEIRO
Presidente e Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.795.341 - RS (2018/0251111-5)

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
RECORRENTE : DALVANI ALBARELLO
RECORRENTE : LUIS FABIANO LEAES NERY
RECORRENTE : SERGIO ARINO DE SOUZA
ADVOGADOS : ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338
 JAIRO LUIS CUTINSKI E OUTRO(S) - RS076915
RECORRENTE : JEFERSON WBATUBA MOTA
ADVOGADO : JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
 SUL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator):

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO - ART. 305, "CAPUT", CPM. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESTRANHAMENTO. 1. Embora possível, como regra, a juntada de documentos em qualquer fase do processo, aqueles imprescindíveis devem ser providenciados no curso da instrução criminal, sob pena de incorrer na violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da lealdade processual, do contraditório e da ampla defesa, torna-se, ilegítima e intempestiva a juntada de documentos aos autos nesta fase processual, em especial, quando restarem conclusos para julgamento. PRELIMINAR. SERENDIPIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LICITUDE DA PROVA. 2. Caso em que o Ministério Público, mediante previa autorização judicial, realizou as escutas telefônicas de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas e que, durante o curso das interceptações e, fortuitamente, obteve êxito ao identificar a prática do crime ora investigado. Havendo autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico em investigação criminal, os outros crimes eventualmente descobertos durante a interceptação também podem ser objeto de persecução penal. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE EXCERTO DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 3. Inexiste a nulidade levantada, uma vez que o agente, como se sabe, defende-se apenas quanto ao conteúdo das gravações utilizadas em seu desfavor e não da integralidade das interceptações. A Lei nº 9.296/96 não exige a transcrição de todas as escutas telefônicas, sendo suficiente a gravação dos conteúdos relevantes para fundamentar a tese acusatória. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. 4. Inexiste a alegada inversão dos papéis atribuídos ao Ministério Público e ao Juiz no caso em concreto, pois não há qualquer previsão quanto à obrigatoriedade de aceitar, como sendo prova absoluta, o documento unilateralmente produzido e não impugnado pela outra parte. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 5. A prova dos autos é inequívoca quanto à ocorrência do crime de concussão, restando demonstrado que os acusados exigiram a vantagem indevida em proveito próprio, o que evidencia a prática delituosa. RECURSO MINISTERIAL. APENAMENTO. 6. Circunstâncias judiciais do caso não excedem



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

a espécie normativa do delito de concussão. Elementos presentes nos autos não revelam nenhuma situação que mereça maior reprovação que justifique o apenamento acima do mínimo legal, uma vez que a pena se mostrou necessária e suficiente à reprovação do crime perpetrado.

Nas razões do recurso especial de DALVANI, LUIS FABIANO E SERGIO apontam violação do art. 1º da Lei 9.296/96 e arts. 378, 379 e 541 do CPPM.

Sustentam os agravantes a nulidade do processo, tendo em vista que a sentença foi *embasada em fornecimento parcial das escutas telefônicas e sem a demonstração da devida autorização de compartilhamento da prova* (fl. 1364).

Apontam cerceamento de defesa e ainda ofensa ao princípio do *reformatio in pejus*, porquanto, em recurso exclusivo da defesa, o Ministério Público procedeu à juntada de petição acompanhada de documento, sem a posterior manifestação dos recorrentes, a qual foi acolhida pelo Tribunal de origem.

Requerem, assim, o provimento do recurso especial, a fim de que seja declarada a nulidade do processo.

No recurso especial de JEFERSON, sustenta contrariedade aos arts. 295 do CPPM e 157 do CPP e arts. 1º, 5º, 6º, § 3º e 8º, todos da Lei 9.296/96.

Alega a nulidade da prova emprestada em razão da falta de juntada da integralidade da interceptação telefônica e da inexistência de autorização judicial.

Busca o provimento do recurso especial no sentido de decretar a nulidade do processo.

Apresentada a contraminuta, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo improvimento do agravo.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.795.341 - RS (2018/0251111-5)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator):

Os recorrentes foram condenados às penas de 2 anos de reclusão, no regime aberto, como incurso no art. 305 c/c 53, ambos do CPM. Interpostos recursos de apelação, o Tribunal de origem, à unanimidade, determinou o desentranhamento dos documentos apresentados pelo *parquet* e, por maioria, negou provimento aos apelos. Opostos embargos de declaração e infringentes, ambos foram rejeitados pela Corte local.

No tocante à interceptação telefônica, consta do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (fls. 1117-1120):

3ª Preliminar - Aventam, também, nulidade por cerceamento de defesa, **ocasionada pela ausência de juntada integral das escutas telefônicas.**

Da leitura dos autos depreende-se que as gravações das interceptações telefônicas foram juntadas aos autos, permitindo ao apelante o exercício da ampla defesa.

O agente, como se sabe, defende-se do conteúdo das gravações e não do "CD" contendo todas as interceptações, que representa mero instrumento utilizado para o registro. Nulidade haveria se não tivessem sido juntadas aos autos as transcrições do conteúdo pertinente ao caso.

De mais a mais, as interceptações foram efetuadas mediante autorização judicial, nos termos do artigo 1º do parágrafo único da Lei nº 9296/96. **E, no curso da ação penal, os réus obtiveram acesso às transcrições, ficando, pois, afastada a alegação de nulidade do processo, a esse título.**

Outrossim, **houve gravação dos principais trechos das conversas** onde se vislumbra o diálogo entre "Dão" e o réu Dalvani Albarello, de modo que a **defesa teve acesso, embora não integral, ao conteúdo das interceptações.**

De outra banda, **tal argumentação defensiva de nulidade pela ausência de juntada integral das escutas telefônicas não se sustenta ante o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:**

[...]

E, ainda que se admitisse, *ad argumentandum tantum*, a nulidade alegada, não poderia ela ser reconhecida, por falta de demonstração do prejuízo.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

[...]

Assim, igualmente merece rejeição a preliminar.

Por oportuno, trago os excertos do voto vencido (fls. 1142-1144):

Até mesmo as gravações e as mídias, produzidas e insertas em autos apartados, não vieram aos autos senão através de excertos extraídos e editados de um todo maior.

[...]

A regra é esta: todo o material objeto das interceptações telefônicas, para servirem **como prova em processo penal, deve ser disponibilizado integralmente às**



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

partes, em especial, aos acusados, para que lhes seja possível exercer ampla defesa. Não há ampla defesa possível diante de áudios descontinuados, sem ordenação, seqüencial lógica e com omissão de trechos da gravação, como ocorre nestes autos, em que os excertos colacionados destas interceptações constituem prova que interessa apenas ao Ministério Público. **Diante disto, ao meu sentir, padece de nulidade absoluta a prova produzida em Primeiro Grau, emprestada, de forma equivocada, de processo estranho à justiça castrense, sem que às partes tenha sido assegurado o conhecimento amplo e completo da prova que serviu de base à condenação criminal que lhes foi imposta.** Assinalo, ainda, que ao exame da sentença combatida, percebe-se que **os fundamentos da decisão condenatória estão embasados nas escutas telefônicas e em prova oral.** Esta, porém, a prova testemunhal, foi cotejada com a prova emprestada, o que significa dizer que a censura penal decorre do entrelaçamento de ambas as provas que compõem o arcabouço probatório. Então, vê-se que a reprimenda penal se assenta em prova nula que contamina a prova que poderia ser eficaz. Sem dúvida, as autorizações judiciais de interceptações telefônicas e de seu compartilhamento com a Justiça Militar, **assim como o conhecimento integral das - mídias e gravações, constituíam documentos e provas indispensáveis ao atendimento do devido processo legal constitucional.**

No caso, conforme consignado no Tribunal de origem, *a defesa teve acesso, embora não integral, ao conteúdo das interceptações* (fl. 1117), o qual foi trazida aos presentes autos de forma emprestada, sendo que [...] *as gravações e as mídias, produzidas e insertas em autos apartados, não vieram aos autos senão através de excertos extraídos e editados de um todo maior* (fls. 1142-1143).

Importante frisar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, de que *não é obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez o art. 9º da Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido e determina que provas que não interessarem ao processo serão inutilizadas*" (RHC 80.986/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 23/11/2017).

Contudo, a presente irresignação mostra-se diversa, refere-se ao acesso à integralidade do monitoramento telefônico. Cabe ressaltar que todo produto decorrente dos áudios obtidos deve ser destinado ao Juízo competente, sendo que a extração do que não for relevante ao processo deve ser realizada em conjunto com acusação e defesa, na forma disciplinada no art. 9º, parágrafo único, da Lei 9.296/96. A propósito:

Art. 9º A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal".

Sendo assim, a questão deve ser analisada a partir da quebra da cadeia de custódia



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

da prova, sendo que esta Corte já decidiu que *tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade* (RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

Desse modo, deve ser facultado à defesa a integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução acerca das partes a serem extraídas, mormente quando atestado no Tribunal de origem a existência de ***áudios descontinuados, sem ordenação, seqüencial lógica e com omissão de trechos da gravação, como ocorre nestes autos, em que os excertos colacionados destas interceptações constituem prova que interessa apenas ao Ministério Público*** (fl. 1143). Nesse sentido, confira precedente da Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inépcia da denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas omissões – nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que não constituem objeto da imputação – não importam em prejuízo à defesa. 2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corrêu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corrêu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso *Nix x Williams* (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. 3. Ilícitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. 3.4 **Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida.** 4. Ordem denegada.

(HC 91867, Relator(a): Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012).

Dessa forma, tratando-se a presente hipótese de falta de acesso à integralidade da interceptação telefônica e não da falta de transcrição ou de gravação integral das conversas obtidas, patente a nulidade. De fato, a apresentação de parcela do produto extraído dos áudios, cuja filtragem foi estabelecida sem a presença do defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizado apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa. A esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO AUTORIZADA JUDICIALMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA COM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES. PRESENÇA DE



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA PRÁTICA DELITUOSA. INDISPENSABILIDADE DO MONITORAMENTO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI DOS DELITOS. CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 2º, I A III, DA LEI 9.296/96. LEGALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PROVA PRODUZIDA NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PARIDADE DE ARMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

[...]

V. Hipótese em que os pacientes foram alvo de Operação deflagrada pela Polícia Federal, denominada "Negócio da China", dirigida ao Grupo CASA & VÍDEO, que resultou na denúncia de 14 envolvidos, como incursos nos crimes dos arts. 288 e 334 do Código Penal e art. 1º, V e VII, da Lei 9.613/98, em que se apura a ocorrência de negociações fictícias, com o objetivo de dissimular a natureza de valores provenientes da prática do delito de descaminho, mediante a ilusão parcial do tributo devido na importação de produtos, pela sociedade empresária.

VI. Se as pretensões deduzidas neste writ, com relação a um dos pacientes, não foram formuladas perante o Tribunal de origem, no acórdão ora impugnado, inviável seu conhecimento pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

VII. A intimidade e a privacidade das pessoas não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição (art. 5º, XII) e pela Lei 9.296/96: a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a impossibilidade de produção da prova por outros meios disponíveis e constituir o fato investigado infração penal punida com pena de reclusão, nos termos do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96, havendo sempre que se constatar a proporcionalidade entre o direito à intimidade e o interesse público.

VIII. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de "ser legal, ex vi do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/96, a interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, se for realizada em feito criminal e mediante autorização judicial, não havendo qualquer afronta ao art. 5º, XII, da CF" (STJ, RHC 25.268/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 11/04/2012).

IX. A decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico dos envolvidos na prática criminosa - cujos fundamentos foram incorporados à decisão de quebra de sigilo telemático - encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96, revelando a necessidade da medida cautelar, ante as provas até então coligidas, em face de indícios razoáveis de autoria ou de participação dos acusados em infração penal (art. 2º, I, da Lei 9.296/96), para a apuração dos delitos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem tributária e formação de quadrilha, punidos com reclusão (art. 2º, III, da Lei 9.296/96), demonstrando que a prova cabal do envolvimento dos investigados na alegada trama criminosa, para complementar as provas até então recolhidas, não poderia ser obtida por outros meios que não a interceptação telefônica, especialmente a prova do liame subjetivo entre os investigados, para identificação, com precisão, da atividade desenvolvida pelos alvos principais, o modus operandi utilizado e as pessoas a eles associadas, em intrincado e simulado grupo de empresas nacionais e estrangeiras, destinado a ocultar



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

seu verdadeiro controlador, cujas negociações revestiam-se de clandestinidade, valendo lembrar que, em casos análogos, é conhecida a dificuldade enfrentada pela Polícia Federal para desempenhar suas investigações, uma vez que se trata de suposto grupo organizado, com atuação internacional e dotado de poder econômico (art. 2º, II, da Lei 9.296/96).

X. Apesar de ter sido franqueado o acesso aos autos, parte das provas obtidas a partir da interceptação telemática foi extraviada, ainda na Polícia, e o conteúdo dos áudios telefônicos não foi disponibilizado da forma como captado, havendo descontinuidade nas conversas e na sua ordem, com omissão de alguns áudios.

XI. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas aos interesses do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação da sua integralidade, sem a qual se mostra inviabilizado o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade da prova.

XII. Mostra-se lesiva ao direito à prova, corolário da ampla defesa e do contraditório - constitucionalmente garantidos -, a ausência da salvaguarda da integralidade do material colhido na investigação, repercutindo no próprio dever de garantia da paridade de armas das partes adversas.

XIII. É certo que todo o material obtido por meio da interceptação telefônica deve ser dirigido à autoridade judiciária, a qual, juntamente com a acusação e a defesa, deve selecionar tudo o que interesse à prova, descartando-se, mediante o procedimento previsto no art. 9º, parágrafo único, da Lei 9.296/96, o que se mostrar impertinente ao objeto da interceptação, pelo que constitui constrangimento ilegal a seleção do material produzido nas interceptações autorizadas, realizada pela Polícia Judiciária, tal como ocorreu, subtraindo-se, do Juízo e das partes, o exame da pertinência das provas colhidas. Precedente do STF.

XIV. Decorre da garantia da ampla defesa o direito do acusado à disponibilização da integralidade de mídia, contendo o inteiro teor dos áudios e diálogos interceptados.

XV. Habeas corpus não conhecido, quanto à paciente REBECA DAYLAC, por não integrar o writ originário.

XVI. Habeas corpus não conhecido, por substitutivo de Recurso Ordinário.

XVII. Ordem concedida, de ofício, para anular as provas produzidas nas interceptações telefônica e telemática, determinando, ao Juízo de 1º Grau, o desentranhamento integral do material colhido, bem como o exame da existência de prova ilícita por derivação, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP, procedendo-se ao seu desentranhamento da Ação Penal 2006.51.01.523722-9.

(HC 160.662/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 17/03/2014.)

Ressalte-se que, de acordo com o voto vencido, os fundamentos da decisão condenatória estão embasados nas escutas telefônicas e em prova oral. Esta, porém, a prova testemunhal, foi cotejada com a prova emprestada, o que significa dizer que a censura penal decorre do entrelaçamento de ambas as provas que compõem o arcabouço probatório (fl. 1144).

Evidencia-se que o emprego de trechos da interceptação pode ensejar a extração de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

conversas descontextualizadas, de modo que sem o acesso ao interior teor das mídias obsta que a defesa possa impugnar no momento oportuno, notadamente quando consignado no voto vencido que a condenação se fundamentou na prova combatida.

Sendo assim, uma vez lastreada a condenação fortemente nas provas obtidas durante o monitoramento telefônico, tendo sido impugnado ainda na origem, constata-se flagrante prejuízo à defesa, em razão de que não foi facultado o amplo acesso à integralidade da prova, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade.

Dessa forma, declarada a nulidade da interceptação telefônica e das provas consequentes, devem retornar os autos para que o Juízo singular profira nova sentença, com base nas provas remanescentes. Na hipótese, entretanto, reconhecida a nulidade, inegável a superveniência da prescrição, que declaro, com fundamento no art. 61 do CPP.

Tratando-se de condenação transitada para a acusação, cujas penas foram fixadas em 2 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Assim, transcorrido lapso temporal superior a 4 anos desde o recebimento da denúncia, em 12/9/2013 (fl. 895), último marco interruptivo da prescrição, e não existindo sentença condenatória válida até a presente data, configura-se a perda da pretensão punitiva estatal.

Considerando a nulidade e a prescrição, ora reconhecidas, ficam prejudicados os demais pleitos recursais.

Ante o exposto, voto por dar provimento aos recursos especiais para declarar a nulidade da interceptação telefônica e das provas dela decorrentes, reconhecendo, por consequência, a superveniência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, de ofício.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEXTA TURMA

Número Registro: 2018/0251111-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.795.341 / RS

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 10002692320169210000 4162013

PAUTA: 07/05/2019

JULGADO: 07/05/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **NEFI CORDEIRO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **NEFI CORDEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO**

Secretário

Bel. **ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: DALVANI ALBARELLO
RECORRENTE	: LUIS FABIANO LEAES NERY
RECORRENTE	: SERGIO ARINO DE SOUZA
ADVOGADOS	: ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338 JAIRO LUIS CUTINSKI E OUTRO(S) - RS076915
RECORRENTE	: JEFERSON WBATUBA MOTA
ADVOGADO	: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
RECORRIDO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **JADER DA SILVEIRA MARQUES**, pela parte RECORRENTE: **JEFERSON WBATUBA MOTA**

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento aos recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.